

1501303-44.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Na mesma linha: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. [...]. 2. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio da acusada, sem autorização judicial e sem o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501303-44.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501303-44.2020.8.26.0302 - Controle 2020/001227

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCELINO BORGES

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190467/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 12807819 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3188/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2190467 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz de Direito: Dr. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

ANTONIO MARCELINO BORGES foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 04/08/2020, por volta das 21h45min, na Rua Francisco Glicério, n.º 1.761, Vila Sampaio, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, o total de 9,1 gramas de crack (diversos fragmentos), quando foi preso por Policiais Militares.

Regularmente notificado (fls. 128), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 184/186), após o que a denúncia foi recebida, aos 23/05/2022 (fls. 207/209). Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

Após audiência, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, a Defesa requereu a realização de diligência policial para localização de eventuais imagens captadas por câmeras de segurança que haviam registrado a ocorrência policial, o que foi atendido a fls. 238/239 (diligência foi negativa), com consequente ciência às partes, tendo o Ministério Público reiterado suas alegações finais apresentadas

oralmente após a audiência (fls. 243).

A Defesa, por meio de memorial, alegando ilicitude da prova decorrente de invasão domiciliar e inexistência de provas, pugnou pela absolvição fundada no art. 386, II e VII, do CPP, bem assim, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, ainda, teceu ponderações acerca da aplicação da pena (fls. 247/257).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, não há que se falar em ilicitude da prova material, pois o tráfico é crime permanente, ou seja, o seu momento consumativo (do iter criminis) se prolonga no tempo, de modo que a manutenção em depósito ou a guarda da substância, para fins de traficância (o que, como adiante se verá, ficou demonstrado que ocorria), caracteriza, a todo momento, o estado de flagrante-delito. Nesse sentido, entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça: [...]. IV - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes) - (STJ - AgRg no HC 607.601/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020). Na mesma linha: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. [...]. 2. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio da acusada, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão da residência, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. [...]. - (STJ - HC 596.946/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020). No mesmo sentido, recente decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de drogas - Recursos defensivo e ministerial - Nulidade em decorrência de suposta violação de domicílio - Não acolhimento - Existência de fundadas suspeitas de que o réu estaria praticando crime grave de natureza permanente - Sentença condenatória - Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Condenação mantida - [...]. (TJSP - Apelação Criminal 1502958-28.2020.8.26.0536; Relatora: Fátima Vilas Boas Cruz; 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2022 - destaquei). Ademais, no caso dos autos, o testemunho dos Policiais foi enfático ao afirmarem que viram o réu em conduta que se subsume a tipo penal antes do ingresso na residência.

A demanda é procedente.

Vejam os.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/6), pela fotografia da droga e dos objetos apreendidos (fls. 20), pelo auto de constatação provisória de substância ilícita (fls. 23/4), e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 84/7 - foi detectada a presença da substância cocaína, na apresentação conhecida como crack).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimentos ao Juízo, o Policial Militar Aguinaldo disse que havia denúncias de tráfico no bairro São José. Passado um tempo, tomaram conhecimento que ele estaria trabalhando em um bar. Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao bar, sendo apreendida quantidade de droga, tendo o acusado se evadido. Dias depois, em patrulhamento no bairro São José, receberam informações de que, se estivessem procurando o réu, ele estaria vendendo drogas na Vila Sampaio, rua Francisco Glicério. Falaram que o comprador diria "Salve", e o réu entregaria a droga, já aparecendo com a droga na mão e servindo no portão. Dirigiram-se ao local, bateram no portão e a testemunha falou: "Salve". Ao que o réu abriu o portão e viu a polícia, correu e jogou uma pochete que tinha na mão, onde encontraram

entorpecente. Abordaram o réu na cozinha da casa.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Marcos.

Formalmente interrogado, o réu negou o cometimento do crime. Afirmou que teve entrevero anterior dias antes do fato, mas o entorpecente era para seu uso. No dia dos fatos, a polícia falou que havia mandado de prisão contra si e foi onde ele estava. A polícia pediu para que vizinha desligasse câmera de vigilância porque iriam fazer diligência. A polícia chegou entrando na residência, sem bater, e não encontraram qualquer droga.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, pois a sua versão, já inconsistente de per si (dentre o mais, quis fazer crer que nem sequer havia entorpecente consigo), permaneceu destoante do contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque os Policiais Militares confirmaram a dinâmica apresentada pela denúncia, especialmente o fato de o réu ter corrido pra o interior da casa logo depois de ter aberto o portão e de ter dispensado a pochete contendo os fragmentos de crack.

Acresça-se, ainda, que a diligência policial para localizar imagens supostamente captadas por câmeras de segurança de imóveis existentes nas proximidades do local dos fatos foi negativa, ou seja, a versão do réu não foi amparada por nenhuma prova. Ademais, quando interrogado na fase policial, oportunidade que estava acompanhado de Advogado, nada mencionou sobre a existência de câmaras de segurança e não arrolou testemunhas (p. ex.: vizinho e sua esposa) que pudessem comprovar a sua versão. Portanto, o seu álibi permaneceu no vazio, porque despido de elementos de convicção razoáveis que o robustecessem, ao contrário da tese acusatória, solidamente patenteada pelas declarações dos ofendidos. [...] – (TJSP - Apelação Criminal 0004477-89.2015.8.26.0568; Relator: Camilo Léllis; 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018 – destaquei).

Considere-se também que a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vários fragmentos de crack [9,10 gramas – fls. 20 e 84/7]), a dinâmica singular da ocorrência (após terem sido informados por uma pessoa de que o réu vendia drogas na sua residência, aonde usuários se dirigiam, batiam no portão e gritavam salve, oportunidade em que o réu os atendia já com as drogas em mãos], Policiais Militares foram até lá e gritaram salve, ocasião em que foram atendidos pelo réu, o qual prontamente correu para o interior da casa e dispensou uma pochete contendo droga), bem como a informação da Delegacia Especializada de fls. 96/9 (no sentido de que havia informações de que o réu estava promovendo o tráfico ilícito de drogas e, por isso, estava sendo investigado), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo drogas). Frise-se que, diante da ocorrência, não se verifica mácula pela entrada na residência, tendo em vista o então atual estágio de flagrante do acusado, verificado pela polícia antes do ingresso.

Ademais, lembre-se de que indícios múltiplos, concatenados e imbricados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação – ressaltando que nem o próprio réu conseguiu sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares, em relação aos quais, aliás, aplica-se a sabida presunção de legitimidade dos atos praticados na condição de agentes públicos que são e aqui em nada infirmada com dados substanciosos. Ademais, confira: [...] Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para a

sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende. [...] (TJSP, Apelação Criminal 1500862-91.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021). Ainda a respeito [...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020). Ademais, conquanto tenha havido certa divergência nos dizeres dos policiais quanto a características da pessoa que teria informado a prática do delito pelo réu, certo é que as informações obtidas, e mediante diligência prévia dos agentes de segurança, mostraram-se verdadeiras, havendo a constatação do delito perpetrado pelo réu. Aliás, com relação às pequenas e irrelevantes contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais civis, tal fato é natural, corriqueiro e só serve para emprestar maior credibilidade à prova testemunhal. (TJSP - Des. Ricardo Tucunduva - Ap. Crim. nº 0082650-08.2010.8.26.0050).

Por outro lado, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida (crack), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Outrossim, deve ser destacada a personalidade desajustada do réu, pois cometeu o crime em questão enquanto cumpria pena no regime aberto (fls. 49/53), evidenciando total menosprezo com a seriedade da lei e da Justiça. Ademais, devem ser considerados os maus antecedentes do réu, contando com cinco condenações definitivas, três por furtos qualificados (Autos nº 186/02 [TJ aos 18/10/2004 - fls. 32], nº 14601-42.2004 [TJ aos 10/08/2011 - fls. 29/30] e nº 13702/09 [TJ aos 02/08/2010 - fls. 28/9]), uma por tráfico de drogas (fls. 30/1 - Autos nº 14958/11 [TJ aos 25/10/2013]) e uma por associação para o tráfico (fls. 31 - Autos nº 16884/11 [TJ aos 26/02/2015]), consistindo esta última em reincidência, que será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto as outras serão consideradas nesta primeira

fase a título de maus antecedentes. Então, diante dessas circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 785 dias-multa, porém com estes últimos calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. No mais, em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme anteriormente destacado, aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida. Então, redimensiono a pena em 9 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão e de 915 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que o réu é reincidente. No mais, não havendo causas de aumento de pena a serem aplicadas, torno a pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), mesmo porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso (CP, art. 33, § 3º), conforme se infere da dosimetria como o todo.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 15/6 e 94). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ANTONIO MARCELINO BORGES, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 915 (novecentos e quinze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo a este processo em liberdade por r. decisão de instância superior (fls. 152/6, 169/171 [alvará de soltura] e 175/80), reconheço ao réu o direito de assim permanecer em caso de recurso.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 15/6 e 94) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA